

1500310-35.2022.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gonçalves da Cunha Júnior

Comarca: Monte Aprazível

Foro: Foro de Monte Aprazível

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... conversas sugestivas de envolvimento com o tráfico (vide fls. 342), enquanto se revela impossível inferir se o caderno de anotações (laudo a fls. 293/300) reflete mesmo dados atuais, à mingua, repise-se, de investigação concreta, tendente à apuração do crime de tráfico.

Assim, muito embora a situação entrevista pudesse, por si, a princípio, gerar indícios de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Monte Aprazível

Foro de Monte Aprazível

2ª Vara

Rua Monteiro Lobato, nº 269, Monte Aprazível - SP - cep 15150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500310-35.2022.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500310-35.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcelo Bogas

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gonçalves da Cunha Júnior

Vistos.

MARCELO BOGAS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, porque no dia 17 de fevereiro de 2022, por volta das 07h30min., na residência localizada na Rua Américo C. Almeida, número 270, bairro Jd. Primavera, nesta cidade e comarca, guardava e tinha em depósito pedras de cocaína e crack, o fazendo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com intuito de fornecer ou entregar as substâncias ilícitas ao consumo de terceiros.

A denúncia teve por base o inquérito policial e, após defesa preliminar (fls. 209/216), foi recebida no dia 31 de março de 2022 (fls. 221/222).

O réu foi citado (fls. 252).

Ao longo da instrução, foram ouvidas as testemunhas tempestivamente arroladas e o réu foi interrogado (fls. 305/313).

Em memoriais escritos (fls. 359/364), o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia, por considerar provadas autoria e materialidade. A Defesa, por sua vez (fls. 394/402), sustentou, preliminarmente, a ilicitude da prova decorrente da prisão em flagrante, por mácula à inviolabilidade de domicílio. No mérito, pugnou pela desclassificação da imputação para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06 e pela aplicação ao caso da causa de diminuição de pena veiculada no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

Processo em ordem, que se desenvolveu sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa. Não há nulidade a ser declarada ou vício a ser sanado.

A preliminar invocada pela defesa não colhe, não padecendo de qualquer nulidade a prova decorrente da busca domiciliar narrada na inicial acusatória.

Com efeito, sem delongas, havia incontroverso respaldo para o ingresso das autoridades na residência do acusado, consubstanciado em mandado de prisão emitido nos autos nº 1500091-10.2022.8.26.0369.0001, desta vara.

Com isso em mente, calha obtemperar que, ao revés do sustentado a fls. 396, os agentes não promoveram diligência vertida à procura de elementos probatórios de qualquer ordem, deparando-se, ao revés, com todo o material apreendido a fls. 70/71 na cômoda do quarto em que se encontrava o acusado, em local visível.

Essa a narrativa do investigador Marcelo Marquesi (fls. 313), não informada pelo agente em seu interrogatório (fls. 313).

Tem-se, logo, contexto claro de não extrapolação dos limites do mandado que permitia a entrada na morada do acusado, assim como de encontro fortuito de entorpecente, a conferir justo motivo tanto para a apreensão da substância ilícita e dos objetos que a circundavam, sugerindo o tráfico, quanto para a autuação em flagrante do responsável.

Quanto ao mérito, constato que a materialidade delitiva foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 67/69), auto de exibição e apreensão (fls. 70/71), laudo de constatação (fls. 73/75), bem como pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 171/173).

No que toca à autoria, encerrada a fase instrutória, respeitada a judiciosa manifestação final do Parquet, conclui-se que a conduta perpetrada não se subsumiu ao tipo veiculado pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, mas sim, ao previsto no artigo 28, da mesma lei, impondo-se a desclassificação com fundamento na regra insculpida no artigo 383, do Código de Processo Penal.

Com efeito, a despeito das informações aludidas pelos policiais Breno Montoro Ulian e Marcelo Marquesi (fls. 313), relacionadas ao prévio conhecimento acerca da prática do tráfico pelo acusado, é dos autos que a diligência reportada na denúncia não decorreu de investigação específica, vertida à apuração do crime em foco, mas de cumprimento de mandado de prisão expedido em outro processo, decorrente da prática, em tese, de crime violento.

A isso se agrega a peculiaridade de que foi apreendida pequena quantidade de substância ilícita (total de 3,19 gramas de massa líquida, conforme nota de fls. 74), compatível com o que um simples usuário deteria para consumo imediato.

Ainda, calha obtemperar que o acusado foi surpeendido no interior de sua residência, sob nítido efeito de entorpecente, como declarado pelo policial Marcelo Marquesi (fls. 313), sem observação de movimentação suspeita nas cercanias (vide considerações do policial Breno Montoro Ulian - fls. 313).

Não havia, outrossim, material para embalo de droga, ao passo que não se sabe sequer se a balança apreendida funcionava, efetivamente, ou mesmo se tinha resquícios de substância ilícita.

O telefone celular do réu não tinha conversas sugestivas de envolvimento com o tráfico (vide fls. 342), enquanto se revela impossível inferir se o caderno de anotações (laudo a fls. 293/300) reflete mesmo dados atuais, à mingua, repise-se, de investigação concreta, tendente à apuração do crime de tráfico.

Assim, muito embora a situação entrevista pudesse, por si, a princípio, gerar indícios de tráfico, tais elementos rudimentares não foram corroborados por prova robusta do propósito mercantil, produzida na etapa judicial.

Evidentemente, a intenção mercantil não pode ser deduzida exclusivamente do histórico criminal do denunciado, já que ao direito penal importa, primordialmente, o fato e não a pessoa do agente.

Nessa moldura, não existindo no contexto dos autos prova segura a evidenciar a prática de tráfico drogas, considerando os fatores acima declinados, impõe-se o reconhecimento da desclassificação já adiantada.

Atente-se para o quanto já decidido pelos tribunais pátrios:

“TÓXICO. Crime de tráfico. Quadro probatório que não traz a necessária certeza

quanto à mercancia. Posse para uso próprio. Depoimento de agentes policiais que indicam ser o réu usuário. Quantidade ínfima de tóxico que exige prova concreta de atos de mercancia para comprovar o crime de tráfico. Ausência dessa prova. Dúvida remanescente que autoriza a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06. Recurso parcialmente provido" (TJSP. Apelação Criminal nº 990.09.125064-3, Rel. Des. Newton Neves, julgado em 01.06.2010, VU).

APELAÇÃO - Entorpecentes - Tráfico - Desclassificação- Prova. Inexistindo prova consentânea de que a droga, casualmente apreendida com um dos agentes, objetivava a traficância, é de se dar relevo à alegação do porte para uso próprio. (TJDF - Ap. Crim. nº 18.021/97 - DF - 1ª T - Rel. Des. Everards Mota e Matos - J. 27.11.97 - DJ 11.02.98 - v.u).

Convém salientar que aludida conjuntura não conduz à remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, na medida em que, segundo assentado pela Colenda Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o julgamento do crime de uso deve ser feito pelo Juiz da desclassificação.

Nesse sentido:

"A despeito de ter desclassificado o delito para infração de menor potencial ofensivo, o Juízo suscitado [Juízo da desclassificação] deve permanecer competente para o julgamento do processo, pois recebeu a denúncia, colheu as provas e inquiriu testemunhas, incidindo, no caso em análise, o artigo 87 do Código de Processo Civil segundo o qual a competência é determinada no momento em que a ação é proposta, devendo portanto, o processo ser julgado pelo suscitado [Juízo da desclassificação]" (TJ/SP, Câ. Esp., v.u., Conflito de Jurisdição nº 994.09.229663-0, vu, j. 10.5.2010).

Registre-se, ainda, que o réu é reincidente em crime doloso (vide certidão de fls. 89/93), não fazendo jus a qualquer dos benefícios veiculados pela Lei 9.099/95. Assim, constatada a procedência parcial da pretensão punitiva estatal, passo a dosar a pena, considerando o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal.

Tomando em conta as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, constato que a ré possui outras passagens criminais, ostentando maus antecedentes (conclusão tomada com base na condenação definitiva oriunda do processo nº 0002276-52.2009.8.26.0369, tramitado na E. 1ª Vara local - fls. 90/91). Por isso, com espeque no artigo 28, II e § 4º, da Lei 11.343/06, fixo a pena em prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 8 (oito) meses, à razão de 5 (cinco) horas semanais, em locais a serem estabelecidos em sede de execução, levando-se em consideração as aptidões do condenado, bem como a disponibilidade das entidades existentes.

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência (artigo 61, II, do Código Penal), firmada com base na condenação definitiva oriunda do processo nº 0002298-03.2015.8.26.0369, tramitado nesta vara (fls. 91), com a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, "d", do Código Penal), restando inalterada a pena. Modificando entendimento anteriormente encampado, passo a reputar viável a operação acima efetuada por considerar que a confissão espontânea pode refletir aspecto positivo sobre a personalidade do agente, caracterizando circunstância preponderante em relação à reincidência, consoante dicção do artigo 67, do Código Penal.

Recentemente a questão foi analisada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que se firmou posição consonante com a ora adotada.

Veja-se:

"É possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal" (STJ Min. Sebastião Reis Júnior REsp 1154752/RS j. 23/05.2012).

Não incidindo causa de aumento ou diminuição, torno definitiva a reprimenda até aqui calculada.

Deixo de cumular a pena prevista no artigo 28, I, da Lei 11.343/2006 em razão de sua reduzidíssima eficácia para a consecução dos fins preventivos e repressivos do direito penal. Deixo de cumular a pena prevista no artigo 28, III, da Lei 11.343/2006, porque o poder público, até onde se sabe, ainda não estruturou cursos

ou programas educativos vertidos à conscientização do usuário sobre os efeitos nocivos das drogas.

Ante o exposto, com esteio no artigo 383, do Código de Processo Penal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, o fazendo para condenar MARCELO BOGAS, qualificado nos autos (fls. 10), como incurso no artigo 28, da Lei 11.343/06, ao cumprimento de pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 8 (oito) meses, à razão de 5 (cinco) horas semanais, em locais a serem estabelecidos em sede de execução, observados os parágrafos 5º e 6º, do artigo 28, da Lei 11.343/06.

Diante da pena aplicada, que não importa no cárcere, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, anotada a situação de prisão por ordem oriunda de outro processo, revogando as medidas cautelares impostas na decisão de fls. 329/330.

Caso tal providência ainda não tenha sido tomada, determino a destruição do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 32, § 1º, da Lei 11.343/06, assim como dos micro pontos de natureza não identificada.

Não existindo fundamento jurídico para a decretação do perdimento do numerário e do celular apreendidos (fls. 70/71), autorizo a restituição ao réu após o trânsito em julgado desta sentença.

Outrossim, após o trânsito em julgado, determino o encaminhamento para destruição dos demais objetos constantes no auto de fls. 45/46, flagrantemente não dotados de utilidade ou valor econômico.

Custas na forma da Lei.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para suspensão dos direitos políticos do acusado enquanto perdurarem os efeitos da condenação, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e expeça-se o necessário para o cumprimento definitivo das penas impostas, realizando-se as anotações e comunicações de praxe, tudo de acordo com as NSCGJ (notadamente com os artigos 393 a 400, do capítulo IV, seção XI, subseção V, Tomo I; do artigo 468, do capítulo IV, seção XX, subseção I, Tomo I; e do artigo 479, do capítulo IV, seção X, subseção III, Tomo I).

P.R.I.C.

Monte Aprazível, 19 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA